

1501439-18.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... e se vê processado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n.º 0030422-68.2018.8.16.0013 - certidão de p. 85).

Ademais, ao tempo destes fatos, contava 20 anos de idade.

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de sua primariedade, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É de se ressaltar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501439-18.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501439-18.2020.8.26.0536 - Controle n.º 341/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 171, caput, do Código Penal, porque no dia 4 de maio de 2020, por volta de 12h, na Rua Oton Feliciano n.º 8, neste município e comarca, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo do estabelecimento denominado Folha Verde, consistente em uma máscara de pano, BCAA Pro Series 120 Caps, Best Whey Morango Milkshake 900g e dois Vita Hand Gel, tudo avaliado em R\$ 195,60. O fez induzindo Raiza Barbosa da Silva, representante do estabelecimento, em erro, mediante fraude.

Diz a denúncia que o acusado ingressou no estabelecimento comercial e disse que pretendia adquirir os produtos citados e que estavam expostos à venda. O réu informou que pagaria o valor mediante transação eletrônica, usando a máquina para débitos que a loja dispunha.

A funcionária entregou a máquina de cartão de débito ao acusado. Ele inseriu um

cartão bancário na máquina e fingiu que efetuava o pagamento. Contudo, em vez de fazer a operação para pagar, ele usou a máquina para imprimir uma segunda via do recibo da última operação válida feita na máquina. Ele entregou o impresso à funcionária, que acreditou ser o recibo do pagamento. Em seguida, o acusado saiu da loja levando as mercadorias que escolheu.

A vítima apenas percebeu a fraude posteriormente e comunicou o ocorrido a outros comerciantes.

Diz a petição inicial que, na mesma data, o acusado foi visto perto do comércio. Ele foi detido por policiais militares, que, em revista pessoal, encontraram os produtos obtidos mediante fraude e um cartão do banco Itaú em nome de Creunice de Queiroz Ruas.

A representante da empresa ofereceu representação criminal a 12 (pp. 65/67)

Recebida a denúncia (pp. 68/69), foi o réu citado pessoalmente (p. 122). A Defensoria Pública ofereceu a resposta de p. 125, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 134).

Na instrução, foram ouvidas a representante do estabelecimento vítima e duas testemunhas (pp. 259/263, 264/267 e 268/270). Prejudicado o interrogatório à vista da ausência do acusado, que não foi localizado pelo oficial de justiça, sendo declarado revel (pp. 257/258).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Ademais, sustentou ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (gravação audiovisual, pp. 257/258).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Ademais, pugnou o reconhecimento da figura do estelionato privilegiado, com aplicação da diminuição da pena ou da sanção isolada de multa. Outrossim, pretendeu a concessão de regime inicial aberto (gravação audiovisual, pp. 257/258).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de p. 8.

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o réu manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram a sua prisão (p. 15).

Em juízo, preferiu à revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório uma vez que o acusado não foi localizado.

E, ao que se tem do contexto probatório, é certo que aqui se tem demonstração inequívoca da ocorrência do crime e de sua autoria.

Raiza Barbosa da Silva, representante do estabelecimento, relatou que o réu havia entrado na loja e sua funcionária o atendeu. Na hora de efetuar o pagamento dos produtos no caixa, o acusado entregou-lhe o cartão para passar na máquina, mas quando foi digitar a respectiva senha, o réu imprimiu o comprovante de pagamento da transação anterior. Não perceberam a fraude naquele momento, mas somente após guardarem o comprovante da venda. Narrou que uma amiga da família chegou ao estabelecimento e foi informada sobre o acontecido. Após fazer compras, ela foi embora. Sua amiga foi em direção ao canal 3, onde ela reside, e encontrou o réu a quatro quadras da loja, com uma sacola igual a do seu estabelecimento comercial. Avisada por telefone pela amiga, foi acompanhada de seu pai ao endereço indicado, bem como alertou a Polícia Militar. Expôs que os produtos consistiam em um pote grande de Whey e uma luva, mas não se recorda dos demais itens que o réu levou. O valor total dos produtos era de aproximadamente R\$ 180,00. Mencionou que conseguiram recuperar as mercadorias intactas, que foram vendidas posteriormente. Informou que o réu chegou a falar que era de outra cidade, mas não se prontificou a pagar as mercadorias em nenhum momento. Explicou que não é difícil imprimir o comprovante da compra anterior na máquina de cartão, porque quando os clientes necessitam de uma cópia, eles próprios conseguem reimprimir o comprovante, mas não sabe como é feita essa operação, pois não costuma ficar no caixa. Citou que faltava

apenas o réu digitar a senha do cartão para concluir o pagamento. Esclareceu que estava na caixa e recebeu das mãos do acusado o comprovante impresso, porém apenas percebeu a fraude após ele deixar a loja (pp. 259/263).

Cristian Carolino Costa da Silva, policial militar, contou que foram acionados via COPOM e, chegando ao local, o réu já havia sido detido. Relatou que após indagar sobre o fato, a representante do estabelecimento comentou que o acusado fez uma compra e, no momento de realizar o pagamento com o cartão, ao invés de inserir a senha na máquina, ele apertou algum comando que imprime a via do comprovante de pagamento da transação anterior. Ela só percebeu a fraude após o réu se retirar da loja com as mercadorias. Informou que Boulevard é um conjunto de lojas e o acusado foi localizado na Rua Jorge Tibiriçá, sendo contido por populares. Relatou que perguntaram ao acusado de quem era o cartão, já que não estava em seu nome, e ele disse que o encontrou na rua e planejou aplicar o golpe para conseguir dinheiro, pois necessitava. Informou que o réu estava sóbrio e aparentava ser pessoa em situação de rua. Acrescentou que o acusado não apresentou nenhum comprovante de compra, bem como nada foi encontrado na revista pessoal. O acusado alegou que se retirou da loja tão logo usou a máquina de cartão (pp. 264/267).

Marco Antonio de Almeida Junior, policial militar, relatou que estava em patrulhamento com seu parceiro e foram acionados via COPOM sobre um indivíduo que teria sido abordado e detido por comerciantes após fazer uma operação fraudulenta com cartão. Soube pela representante da loja que o réu simulou ter realizado o pagamento pelos produtos. Assim, pegaram as mercadorias e os conduziram ao distrito policial. Informou que o acusado explicou que achou o cartão e que o colocava na máquina, fingia que tinha dado erro e, quando a pessoa lhe entregava a máquina, o réu apertava enter e imprimia a via do comprovante de pagamento da transação anterior. A pessoa acreditava que a via impressa se tratava do comprovante de pagamento da compra por ele realizada (pp. 268/270).

Vê-se assim, que a prova amealhada – colhida sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa – se revela coerente e uníssona, dando sustento à condenação, nos termos pretendidos na petição inicial.

Os depoimentos são seguros e não há contradição capaz de retirar valor do contexto probatório.

Em juízo, a representante da empresa confirmou que o acusado foi até à loja e escolheu alguns produtos. Na hora do pagamento, o réu entregou-lhe o cartão para passar na máquina e, simulando a digitação da senha, ele emitiu o comprovante de pagamento da última compra efetuada com o uso daquela máquina, o que a fez acreditar que a transação e pagamento haviam sido regularmente realizados.

Esclareceu que somente após o acusado deixar a loja ela constatou que o comprovante emitido era, na verdade, a reimpressão de compra anterior.

Contou, ainda, que com a ajuda de uma amiga, localizou o acusado a algumas quadras da loja e acionou a Polícia Militar, recuperando todas as mercadorias.

Os policiais militares, por sua vez, declararam que encontraram o acusado já detido, sendo informados que ele havia praticado uma fraude no estabelecimento comercial.

Afirmaram, ainda, que o acusado admitiu informalmente que havia achado o cartão em nome de terceiro. O réu também explicou como realizava a fraude, relatando aos policiais que colocava o cartão na máquina, fingia a ocorrência de algum erro e, quando o logista entregava a máquina em suas mãos, apertava enter e imprimia a via da operação de compra realizada anteriormente.

Evidente está que o juízo não poderia desconsiderar as declarações prestadas pela representante do estabelecimento comercial e pelos policiais militares, pois se tratam de informações coerentes e seguras, que retratam a trama encenada pelo réu, para assim obter vantagem para si, induzindo em erro a comerciante.

É certo, pois, que o acusado obteve vantagem ilícita enganando a representante da empresa, pois a fez entregar as mercadorias sem que percebesse que o comprovante de pagamento emitido pela máquina de cartão era de uma compra anterior.

Conclui-se, portanto, que a prova aqui reunida revela que, com astúcia ímpar, o acusado iludiu a confiança da comerciante simulando uma verdadeira compra.

E, por certo, não se cogita de conduta atípica, como pareceu ao ilustre Defensor

Público, já que inaplicável à situação ora analisada o princípio da insignificância.

Não há como admitir que o estelionato seja socialmente tolerado ainda que a vantagem ilícita seja de pequeno valor (bens avaliados em R\$ 195,60 – p. 8) ou porque a vítima não teve prejuízo financeiro com o crime em razão da recuperação da res.

Essa conduta exige pronta repressão estatal, uma vez que perceptível a gravidade desse proceder, exigindo-se submissão dos autores dessa espécie de conduta à sanção penal seja para realização dos valores sociais, bem como para adequada aplicação da lei e restabelecimento da ordem jurídica, abalada pelo comportamento considerado criminoso.

Na verdade, a invocada atipicidade em razão do princípio da insignificância seria causa supralegal de exclusão de tipicidade. Todavia, é de duvidosa caracterização, ainda que se trate de bens de valores reduzidos, ou porque ausente prejuízo financeiro para a vítima diante da recuperação do bem.

“Não há falar-se em atipicidade da conduta. O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do denominado princípio da insignificância. Basta rememorar o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que faz referência ao “pequeno valor” da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa. Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem subtraído é diminuto. Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão veiculada na impetração. Aliás, não se pode olvidar que a aludida causa de exclusão da tipicidade é supralegal, de sorte que há corrente jurisprudencial que não a reconhece. Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara: “Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime de bagatela, posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível.” (TJSP - 14ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. Ap. Crim. nº 990.08.089790-0, j. 05.03.2009, v.u.).

“...Também, não é caso de absolvição por atipicidade da conduta, diante da adoção do princípio da insignificância. Ora, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age infringe a lei penal, violando uma regra básica de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que não muito valiosas ou de pequeno valor. O furto é crime contra o patrimônio e, por isso, a coisa subtraída precisa ter algum valor econômico. Mesmo que considerado pequeno o valor da res, o que importa neste e em todos os casos semelhantes é o desvalor da conduta praticada pelo agente, a qual é típica, pois prevista na legislação penal em vigor como crime de furto. Portanto, a subtração de bens, mesmo que de pequeno valor, “não pode ser tida como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ Resp 828181/RS - Rel. Min. Laurita Vaz DJU 6.8.2007, p. 654; HC 53139/PB - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJU 26.11.2007, p. 249). Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa que cabe ao legislador, é o resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. Portanto, subtrair coisa alheia móvel, segundo a legislação em vigor, continua sendo crime de furto, dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o Juiz, principalmente, não pode ignorá-la negando-lhe aplicação. A previsão de sanções leves para crimes leves, ou a exclusão do crime por atipicidade da conduta, são tarefas que cabem exclusivamente ao legislador, que vem se desincumbindo de seu papel, como fez ao criar a figura do “crime de menor potencial ofensivo”, prevendo o reconhecimento de “crime privilegiado”, permitindo a substituição da pena corporal por restritiva de direito etc. Para CLAUX ROXIN o primeiro a falar no princípio da insignificância o Direito Penal não deve se preocupar com condutas incapazes de lesar qualquer bem jurídico porque se a finalidade da lei penal é

tutelar um bem jurídico, quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível, não será possível proceder-se ao enquadramento por absoluta falta de correspondência entre o fato descrito na lei e o comportamento iníquo realizado. Assim, os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos (in "Curso de Direito Penal", de FERNANDO CAPEZ, Saraiva, 2000, vol. 1, pág.16). Segundo os léxicos, a expressão "insignificante" é sinônima de bagatela. Insignificante é o que nada significa, que não tem valor, é coisa sem importância, inútil. A expressão "nada" quer dizer coisa nenhuma, não existente, de nenhum valor, vã, nula (Constituição Federal dicionários Aurélio, Houaiss, Mirador, Silveira Bueno). Pois então, no caso em apreço, constata-se que não se trata da subtração de coisa insignificante; não se trata de um palito de fósforo, de um alfinete usado, de um prego, mas de diversos objetos de uso pessoal da vítima e uma ferramenta de trabalho, uma máquina "Makita", que não foi recuperada. O valor total dos bens foi estimado em R\$ 134,10 (cento e trinta e quatro reais e dez centavos fls. 16/18). Portanto, não se pode dizer insignificante o crime praticado pela ré. Por derradeiro, caso o pequeno valor da res furtiva leve, sempre, à aplicação da insignificância e ao reconhecimento da atipicidade penal, não haverá tutela jurídica ao patrimônio de estabelecimentos comerciais que trabalham com miudezas, com armarinhos, ou seja, "lojinhas de turco". Nesse teor a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser conferido o seguinte precedente: RHC 6.319/PR, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 23/06/97, p. 29.166. E faz-lhe coro vultosa jurisprudência: RT 587/428, 602/342, 703/351, 723/674, 728/614, 743/673 e 746/622"... (TJSP - 4ª Câmara Criminal - Rel. Des. Euvaldo Chaib - Ap. Crim. nº 0040857-21.2012.8.26.0050 - j. 25/02/14)

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é primário (pp. 21/23) e se vê processado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n.º 0030422-68.2018.8.16.0013 - certidão de p. 85).

Ademais, ao tempo destes fatos, contava 20 anos de idade.

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de sua primariedade, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É de se ressaltar que a menoridade penal, ainda que reconhecida, não altera a fixação da pena, pois a pena-base foi tomada no mínimo legal.

Registre-se, ainda, que é de se reconhecer a ocorrência do estelionato em sua forma privilegiada, pois forçoso entender que de pequeno valor o prejuízo apurado (R\$ 195,60).

Assim, parece razoável que, à vista desse valor, a pena a ser aplicada pela prática do estelionato seja apenas a pena pecuniária, situação essa que também se verificaria se substituída fosse na forma do previsto no artigo 44 do Código Penal. Desta forma, e à vista do disposto no artigo 171, parágrafo 1º, in fine, do Código Penal, fica o réu condenado ao pagamento de pena pecuniária correspondente a 10 (dez) dias-multa.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 171, caput e parágrafo 1º, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 25 de janeiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA